

1502299-98.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Ademais, ele sabia sobre a "casa do tráfico", o que indica conhecimento dos trâmites e práticas do tráfico, não se trata, portanto, de um mero colaborador que não tem ciência nem relação com os outros processos do tráfico.

Confira-se, a propósito:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502299-98.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502299-98.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MATHEUS SOUZA DUBOVICKI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MATHEUS SOUZA DUBOVICKI, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 12h, na Rua Joaquim Manoel Macedo, 196, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com agente não identificado, guardava e mantinha em depósito para entrega ao consumo de terceiros 135 eppendorfes de cocaína e 40 papелotes de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 8), assim como o laudo de constatação (fls. 10/13) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 145/147).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 110) e apresentou defesa preliminar (fls. 122/135). Em 24 de janeiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 136).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) MATHEUS SOUZA DUBOVICKI foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque 13 de outubro de 2020, por volta das 12h, na Rua Joaquim Manoel Macedo, 196, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com agente não identificado, guardava e mantinha em depósito para entrega

ao consumo de terceiros 135 eppendorfes de cocaína e 40 papелotes de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com a denúncia, policiais civis investigavam o tráfico de drogas no local do fato, viram o réu e outro rapaz, o primeiro avisava sobre a chegada de usuários e o segundo agente entregava as drogas. Conseguiram deter somente o réu, que admitiu ser olheiro do tráfico e informou onde estavam armazenadas as drogas. Tratava-se de uma casa e num quarto, sobre a cama, estavam os entorpecentes acima discriminados.

A quantidade e dupla variedade de entorpecentes não permitem pensar em porte para uso próprio. As provas produzidas durante a persecução penal, peças informativas durante a investigação e provas propriamente ditas em juízo, demonstram que havia mesmo tráfico de drogas no local dos fatos.

Na fase policial e em juízo ele disse que atuava como olheiro; deveria avisar sobre a chegada de policiais ou potenciais compradores. Não era proprietário nem responsável pelas drogas apreendidas, elas estavam na "casa do tráfico". Cuida-se de admissão de participação porque representa auxílio à autoria do crime, isto é, à prática das condutas típicas previstas em lei.

Em solo policial e em juízo, a testemunha Joaquim relatou que é policial civil e participou da diligência no local do fato. Observou a presença de dois homens, um deles, o réu, parecia avisar o outro sobre a chegada de usuários. O segundo agente então trazia os entorpecentes para serem entregues aos compradores. Conseguiram abordar somente o réu, o comparsa fugiu. Na ocasião, o réu admitiu que era olheiro e indicou uma casa desabitada onde estavam guardadas as drogas. Aparentemente era um local que servia ao tráfico, e havia mais de cem porções de drogas, entre maconha e cocaína, sobre a cama.

Parece claro que o réu colaborava com traficantes, mas não há por que duvidar da afirmação dele de que não tinha relação com as drogas apreendidas. Ele não foi visto com drogas, nem foram apreendidas sob posse direta dele, tampouco há indicativo de que a casa onde encontradas as substâncias fosse do réu.

Nessa linha de ideias, afiguram-se duas possibilidades: pode ser desclassificada a conduta para a do artigo 37 da Lei 11.343: Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34. Ou poderia ser o subsumir-se o fato ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, o que compreendo ser a posição mais acertada.

O réu não especificou desde quando atuava como olheiro, mas deu a entender que isso era rotineiro. Ademais, ele sabia sobre a "casa do tráfico", o que indica conhecimento dos trâmites e práticas do tráfico, não se trata, portanto, de um mero colaborador que não tem ciência nem relação com os outros processos do tráfico.

Confira-se, a propósito:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. DELITO DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESSUPOSIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ENVOLVIMENTO COM O GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

MANUTENÇÃO DE VÍNCULO. DIVISÃO DE TAREFAS. FUNÇÃO INTERNA DE SENTINELA, FOGUETEIRO OU INFORMANTE. CONFIGURAÇÃO DE TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE. TRÁFICO OU ASSOCIAÇÃO. 3. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO. ARTS. 35 E 37 DA LEI Nº 11.343/2006. AGENTE QUE EXERCE FUNÇÃO DE INFORMANTE DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DA QUAL PARTICIPA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA APENAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 4. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 5.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006 E ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando,

mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante.

3. O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave.

De fato, cuidando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem.

4. Além de o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o crime de associação nem sequer é equiparado a hediondo, não havendo se falar, portanto, em regime fechado decorrente de imposição legal.

Fixada a reprimenda no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias negativas, mostra-se adequada a aplicação do regime aberto, nos termos do que disciplina o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar a condenação pelo delito descrito no art. 37 da Lei nº 11.343/2006, mantendo apenas o édito condenatório pelo crime de associação, alterando-se, no mais, o regime de cumprimento da pena para o aberto."

(HC 224.849/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Vejo que o réu já foi condenado duas vezes na seara da infância e juventude por atos análogos ao tráfico de drogas (fl. 26), mas deixo de levar isso em consideração para reforçar a conclusão supra porque são eventos antigos, do ano de 2016, quatro anos antes do fato sob exame, de sorte que a conexão fixa mais frágil. Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (mil e duzentos) dias-multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena poderia(m) ser considerada(s) a(s) atenuante(s) da menoridade de 21 anos na data dos fatos e da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. Todavia, estando a pena-base no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, não é possível tal redução.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 3 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e substituo essa pena por prestação de

serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 300 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) MATHEUS SOUZA DUBOVICKI, como incurso no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há elementos novos que devam agora fundamentar a modificação dessa situação, logo, permito que o réu assim permaneça até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 8 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA